



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 274/10

- בענין :**
1. פטרזיל מנחם (חלקת משנה 10)
 2. פנצ'ק נפתלי ת.ז. (חלקת משנה 11)
 3. לוסקי מרים ת.ז. (חלקת משנה 2)
 4. רוזנטל רוני ת.ז. (חלקת משנה 4)
 5. נוימן יהושע ת.ז. (חלקת משנה 5)
 6. ברעם חוה ת.ז.
 7. לצרס דוד ת.ז. (חלקת משנה 1)
 - לצרס חבי ת.ז.
 8. רויטמן משה ת.ז. (חלקת משנה 3)

ע"י ב"כ עוה"ד רון אביב
מרח' הבנקים 3, חיפה
ת.ד. 1030, חיפה 31000

התובעת

נגד

1. אברהם מזרחי ת.ז.
לינדה מזרחי ת.ז. (חלקת משנה 6)
עזבון המנוחה סביחה מזרחי ת.ז.
2. משה בכר ת.ז. (חלקת משנה 8)
לאה בכר ת.ז.

ע"י ב"כ עוה"ד פנחס וולר
מרח' העצמאות 15, חיפה ת.ד. 33892, חיפה
33138

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

1. עילת התביעה בהליך זה הנה מיזם אותו מבקשים הנתבעים לממש, שעיקרו תוספת ממ"דים בקומות 3 ו 4 של הבית המשותף, חרף התנגדות רוב בעלי הדירות באותו בית משותף. עסקינן בבית המשותף ברח' הנטקה 19, חיפה, המזוהה גם כגוש 10782 חלקה 68.

2. התובעים, כל אחד לחוד, הנם בעלים של 7 דירות בבית המשותף [מצאתי שלא למנות את תובעת מס' 6 על רקע הודעה אודות בריאות מנטלית לקויה שלה], והנתבעים, כל אחד לחוד, בעלים של 2 דירות בבית המשותף. כך יוצא ש מרבית בעלי הדירות בבית הנדון (למעט בעלי חלקת משנה 7 שתומכים בבקשת ההיתר) הם צד להליך.

3. נטען בכתב התביעה כי הרחבת הדירות כמתוכנן על ידי הנתבעים, מגדל ש יכיל ממ"ד לכל דירה, תפגע בזכויות הקנייניות של יתר בעלי הדירות, שעיקרן פגיעה חמורה באוויר ובאור השמש המגיעים כיום לדירות הבית עד כדי חסימה מוחלטת שלהם, כמו גם פגיעה בחזות הבניין, אשר עבר זה מקרוב שיפוץ מקיף, וצמצום החצר הפנויה מחלקים מבונים. תימוכין לעמדתם מוצאים התובעים בהערכת וועדת הערר המחוזית שדנה בערעור על היתר הבנייה שניתן לנתבעים, שמצאה גם היא פגיעה חזותית בבניין, אם הרחבת הדירות תתאפשר. התובעים מציינים כי דירות הנתבעים כבר הורחבו בעבר שלא על פי היתר בנייה, היינו שלא כדין – עילה נוספת המבססת את היעדר הזכות של הנתבעים לממש את היתר הבנייה שניתן להם לאחרונה, וכן מבססת העדר תום לב מצדם. התובעים גם מציינים כי בבית המשותף קיים מקלט עם נגישות נוחה אליו, מה שמצמצם את הצורך בממ"ד. הבנייה גם תקשה על נגישות לשעוני המים, וכן תשפיע על תוואי צנרת המים/הניקוז המשמשת לדירות הבית.

4. הנתבעים לעומת זאת, טוענים כי יש להם הזכות לממש את היתר הבנייה שקיבלו, מטעמים של שיהוי/מניעות, בשים לב למועד הגשת התביעה (16.12.10) לעומת המועד בו ניתנה החלטת וועדת הערר שאישרה את היתר הבנייה (19.10.10), מה שגרם לנתבעים הוצאות כספיות לא מבוטלות הכרוכות בתשלום אגרות והוצאות נלוות המהוות תנאי למתן ההיתר. כמו כן טוענים הנתבעים כי הממ"דים המתוכננים להיבנות זה מעל זה בפאה אחת של הבית המשותף כמעט לא נצפים מהדרך הציבורית, בשים לב לטופוגרפיה של החלקה. בנוסף, הבעלים של חלקת משנה 9 אינם נמנים עם התובעים, ולעומת זאת תובע מס' 4 אינו בעל זכויות קנייניות. הנתבעים רואים בהתנגדות התובעים משום חוסר תום לב ומימוש לרעה של זכות קניינית, זאת לנוכח צורך חיוני ביותר בחדרי ממ"ד והעדר כל נזק בעטיים, ולכל היותר נזק מזערי, לתובעים ו/או לרכוש המשותף. ובכלל, טוענים הנתבעים, כי משלא ערערו לבית המשפט לעניינים מנהליים, מיצו התובעים את זכותם לטעון כנגד היתר הבנייה וכי החלטת וועדת הערר המחוזית היא בבחינת מעשה בית דין. הנתבעים הצביעו גם על עבירות בנייה של התובעים או מי מהם, מה ששולל את זכותם של האחרונים להעלות טענה כנגדם.

5. הבית המשותף הנדון רשום בפנקס הבתים המשותפים. כאמור הוא מונה 11 דירות: שתי דירות בכל קומה, ושלוש דירות דופלקס זו לצד זו בקומות רביעית + חמישית. על פי תשריט הרישום הדירות בנויות באופן מדורג.

6. ביום 6.10.11 קיימתי ביקור במקום במהלכו הפנו אותי הצדדים לנתונים הרלבנטיים מבחינתם, מצאתי מתוך הללו לציין את הנתונים הבאים:

(א) למביט בבית המשותף מהרחוב נצפה מבנה מתוחזק ומטופח למשעי. ניכר כי המעטפת עברה שיפוץ איכותי זה מקרוב. ביקור במבנה עצמו מלמד על תחזוקה ראויה שלו לרבות תחזוקה ראויה ומטופחת של חלק החצר הנגיש של הבית [הבית בנוי במדרון תלול ולכן החצר העורפית לא נגישה].

(ב) המבנה מאופיין בסימטריה באופן שבכל אחת מארבע הקומות הראשונות ישנן שתי דירות, ומעל בשתי הקומות העליונות ממוקמות 3 דירות דופלקס זו לצד זו, לרוחב המבנה.

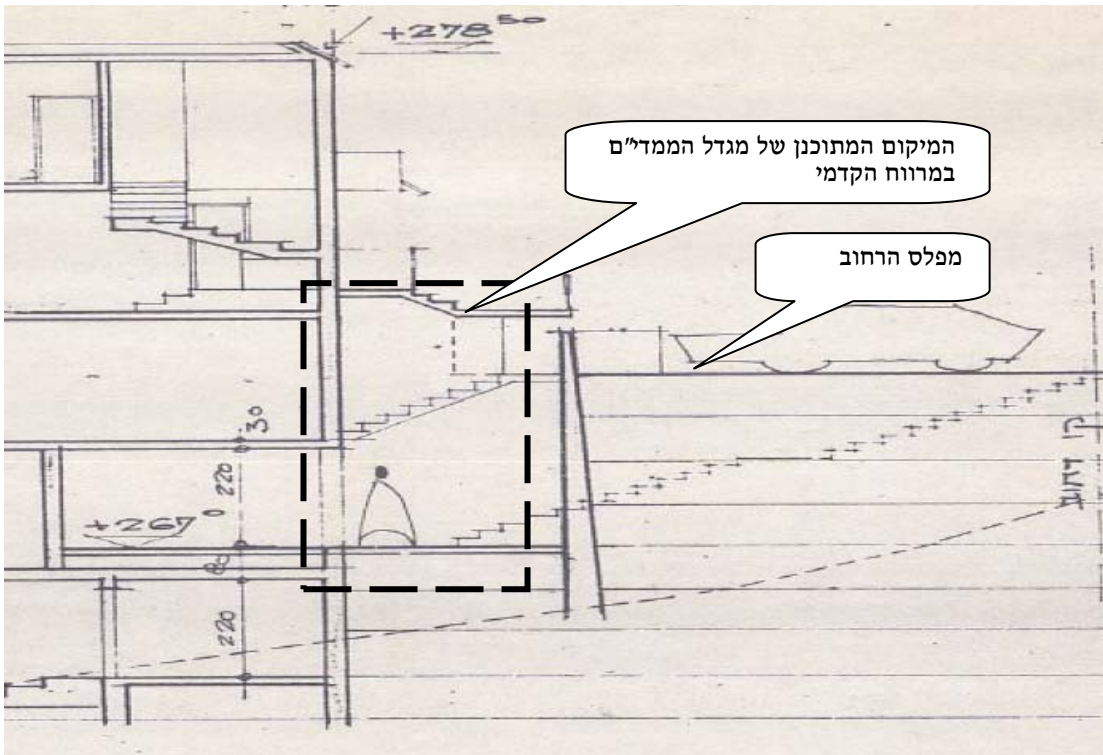
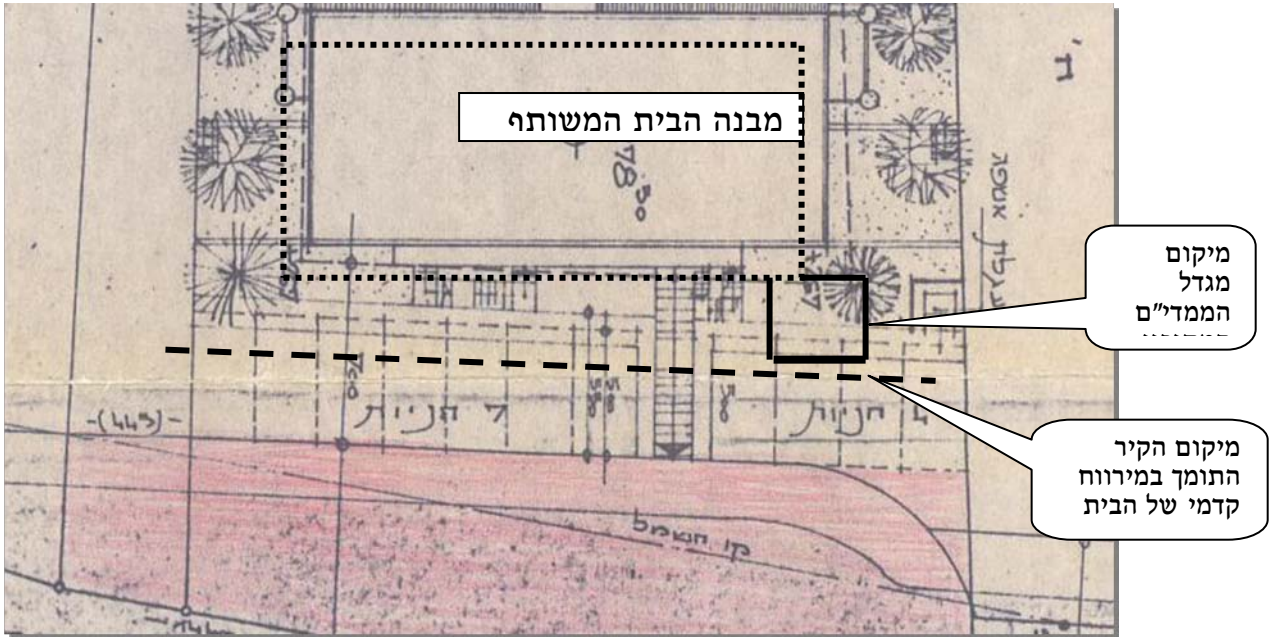
(ג) מפלס החלקה נמוך משמעותית ממפלס הרחוב. מפלס הרחוב מקביל לקומה השלישית של הבית המשותף; הקומות התחתונות לא נצפות מהרחוב; חלק מהקומה השלישית וכן שתי הקומות העליונות הן שנצפות מהרחוב.

(ד) המרווח הקדמי בין הבית לבין הקיר התומך בחנייה הפרוסה בחזית הבית רוחבו כ- 3 מ'. זה המרווח בו מבקשים הנתבעים למקם את הממ "ד. במרווח בנוי גשר גישה, חלקו מפולס וחלקו מדרגות, המחבר את המדרכה הציבורית למבנה; המדרגות המשותפות המובילות לדירות הבית במורד החלקה, אינן מקורות וחוצות את המבנה באופן שבכל קומה ישנן שתי דירות, אחת מכל עבר של המדרגות.

(ה) בקומה ראשונה ממוקמים מקלט ומחסן משותפים מהעבר האחד של המדרגות המשותפות, וחדר הסקה עם מבואה מהעבר האחר של חדר המדרגות. נטען כי בעלי חלקת משנה 4 תפסו חזקה ייחודית בחדר ההסקה המשיק לדירתם.

(ו) בקדמת חלקת משנה 6, לכל רוחב הדירה, נצפה חדר סגור אשר על פי תשריט רישום הבית המשותף היה מרפסת מקורה בתחומי הרכוש המשותף ושטחה 23 מ"ר.

(ז) מיקום הממ "ד המוצע מודגם ב שני התרשימים המובאים מטה, הראשון בתרשים החלקה והשני חתך החזית הקדמית:



7. העידו בפניי 6 עדים מטעם התביעה המייצגים חמש דירות , כל עד ונימוקיו להתנגדות לבניית מגדל הממ "דים. העדים כולם העידו על יחסי השכנות ההדוקים שאפיינו אותם במשך שנים רבות , עד להולדתו של מיזם הממדי "ס. כחוט השני עוברת בעדויות ההתנגדות לשינוי חזית הבית שהנה כיום משטח מגוון ומוצל על ידי צמחיה הגדלה לגובה, וכן שימת דגש על חסימת אור ואויר הן למפתחי הדירות והן למעברים המשותפים אל הדירות בעטייה של הבניה המתוכננת. נוספים על כך חששות סובייקטיביים של העדים, כפי שייסקרו בעת שאתייחס לכל עדות בנפרד.

8. התובעים סיכמו את טענותיהם , בקצירת האומר , לאמור: הם רואים בבניה המתוכננת משום פגיעה בזכויותיהם הקנייניות ; תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף ; פגיעה במידת ההנאה שלהם מ דירותיהם ומהרכוש המשותף ; הנתבעים נעדרי הסכמה מפורשת של הרוב הקבוע בחוק למימוש תכנית הבניה ; לנתבעים גם אין הזכות להסתמך על שיהוי או על הסכמה מצד מי מהנתבעים מהטעם שהללו גילו התנגדותם הנחרצת כבר בשלבים הראשונים של בחינת הבקשה להיתר בנייה אצל רשויות התכנון ; כפיית דעתם כמיעוט על התובעים שהנם הרוב בבית המשותף מהווה חוסר תום לב.

9. הנתבעים לעומת זאת בדעה שהתובעים, עליהם מוטל נטל הראיה להוכיח את רכיבי עילת התביעה, לא הוכיחו התנגדות של הרוב מבעלי הדירות הקבוע בדן. הנתבעים רואים בעצם הגשת התביעה משום חוסר תום לב ושימ ויש לרעה בזכות על רקע נחיצות מיגון הדירות בעיקר באזור חיפה . הם סורקים את עמדות העדים שהעידו ומוצאים כי רשויות התכנון כבר בחנו אותן ומצאו להעדיף את בניית הממ "דים על פניהן, בין היתר בשים לב להעדר שימוש כלשהו בחלקת החצר עליה מתוכננים להיבנות הממ "דים. עוד מצביע ים הנתבעים על מקצת התובעים שכבר הרחיבו דירותיהם על חשבון הרכוש המשותף ולפיכך הם בחזקת מסכימים להרחבה נשוא התביעה.

דיון

01. סעיף 71ב(א)' לחוק המקרקעין כמתכונתו דהיום מאפשר בניה ברכוש המשותף לצורך הרחבת דירה גם בהיעדר הסכמה של כל בעלי הדירות . מצב משפטי זה החליף את קודמו ששלט בכיפה עד 1995 ולפיו רק בהסכמת כל בעלי הדירות ניתן היה לעשות שימוש ברכוש המשותף לשם הרחבת דירות . תוך שהוא מודע לחשיבות מרחבים מוגנים דיר תיים [ממדי"ם] קבע המחוקק – בתיקון משנת 2008 – כי הרחבת דירה על חשבון הרכוש המשותף שמטרתה בניית ממ "ד מותנית בתנאים מקלים עוד יותר, וזו לשונו היום בחלקיו הרלבנטיים :

"...רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה. ואולם היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי ... רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם ששים אחוזים מהדירות" [ההדגשה שלי-צ.פ.].

17. דא עקא שמצב משפטי רצוי זה, ששם סוף לאפשרות החוקית שהיה בידי בעל דירה אחד לתקוע יתד בגלגלי מימוש זכויות בניה לצורך הרחבת דירות, יוזמה שזכתה להסכמה רחבה [אם כי לא מוחלטת] של בעלי הדירות, וזאת חרף היעדר פגיעה מהותית בזכויותיו שלו, לא מקנה לבעל דירה זכות 'לזנב' בתנאי זה. לאמור: התנאי הקבוע בסעיף שצוטט מעלה, היינו הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית המשותף, הינו תנאי בלתו-אין ורק בהתמלאו עומדת לבעל דירה זכות להרחיב את דירתו לשם בניית ממ"ד.

האמור נסמך על עש"א [חי'] 22123-10-10 חדד נ' זינגר שם נפסק:

"בעוד שעד לתיקון מס' 18 נדרשה הסכמת כלל הדיירים כדי לבצע הצמדה כזו...הרי שתיקון 18 מבטא מדיניות חקיקתית החותרת לבטא את הצרכים של כלל בעלי הדירות להרחבת דירותיהם לצרכי מגורים ולשם פתרון של מצוקות הדייר תוך הפחתת זכותו של המיעוט לנהוג בשרירות בקניין ולבצע שינויים המיטיבים עם הכלל. לשם כך נקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כי לבעלי רוב מיוחד בבית המשותף יהא כוח להחליט על הצמדת חלקים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת 'לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה'..."

קדם לו ע"א [חי'] 835/08 צבי נ' פרי ואח' שאחז באותה הדעה:

"במשטר שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין נתן המחוקק את הכוח בידי רוב בעלי הדירות 'להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה'. במילים אחרות, הרכוש המשותף מוגן ב'הגנה קניינית', ולצורך הסרת ההגנה דרוש רוב מסוים שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. הפועל היוצא מכך הוא שמי שאינו מצליח לגייס את הרוב הדרוש...לא יוכל לקבל חלק מסוים מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו" [ההדגשות שלי-צ.פ.].

21. זאת ועוד, בזיקה לטענות ב"כ הנתבעים ולפיהן היעדר התנגדות כמוהו כהסכמה, יודגש כי הפסיקה התנתה 'הסכמה' בכל אשר נוגע למימוש זכויות קנייניות של האחד שתוצאתן פגיעה בזכויות קנייניות של האחר בכך שהיא תהיה מפורשת

מוגדרת חד משמעית ואינה משתמעת לשני פנים . ראה ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי פ"ד נ"ד(3) 389 לאמור :

"ג"שה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף , ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש". (ההדגשה שלי – צ.פ.).

כך גם בע"א 239/79 - ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2), 807 שם נפסק :

"כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוקנות ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללא בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא , ותחומי הפרט , מאידך גיסא. "

וכן ראה פסק דינו של כב' ' השופט דר' בנימיני בה"פ 1266/03(מחוזית"א) מיום 25.11.07 והפסיקה הענפה אליה הוא מפנה בפרקים 18-19 לפסק הדין.

37. יוצא מכאן כי אמנם מקום שתפיסת החזקה ברכוש המשותף נועדה לשם הרחבת דירה קבע החוק הסכמה מופחתת , אך עדיין חובה שתהיה מפורשת וחד משמעית . ללמדנו כי היעדר התנגדות אינו שקול כנגד הסכמה , לא כל שכן הסכמה מפורשת . ועוד, חובת ההוכחה לקיומה של הסכמה רובצת לפתחו של מי שמבקש להיבנות – תרתי משמע – מההסכמה המפורשת , ולטעון כי עומדת לו הזכות לבנות . אפילו דעתו המקלה של כב' ' השופט רובינשטיין בעע"מ 2832/09 מיום 9.1.2011 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ ואח', אשר מסתפקת למצער בהסכמה משתמעת [פסקה כו' לפסה"ד], אינה מזהה 'היעדר התנגדות' כ'הסכמה' של יתר השותפים בנכס.

47. עוד אני מוצאת להפנות לחוות דעתו של כב' ' השופט סוקול בעש"א [חי'] 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב מיום 16.8.2010, לאמור :

"... גם אם לא מושגת ההסכמה משיקולים הנראים בעיני המבקש כפסולים אל לו לעשות דין לעצמו ועליו לנקוט בהליך מתאים בבית ה' משפט או בפני המפקח כדי לכפות את ההסכמה".

57. נבחן אפוא להלן האם מן הדין לייחס לתובעים שהעידו התנגדות קנטרנית נטולת תום לב ולאחרים האם ניתן לייחס הסכמה בדמותה הקניינית להם מחויבים.

(א) הנתבעים מבקשים לייחס למש' רוזנטל הסכמה קונסטרוקטיבית מכוח הרחבת דירתם שלהם על חשבון חדר ההסקה שהינו רכוש משותף. הגנה זו מושתתת על סעיף 71ב[ג] המעמיד כל בעל דירה שהרחיב את דירתו בחזקת מסכים להרחבה דומה של דירה אחת, מה שמייצר הסכמה מפורשת שלו. השאלה היא אם אכן ניתן לראות בהרחבת דירת רוזנטל 'הרחבה דומה' לזו המתוכננת על ידי הנתבעים.

(ב) הפסיקה קבעה מאפיינים ל הרחבות דומות. אין הכרח שההרחבה תהיה זהה, די בכך שהיא תהיה דומה. בפסה"ד בענין חדד נ' זינגר חיווה בית המשפט את דעתו וציין כי:

"נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבנין"

ועוד –

"הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי".

והלאה משם –

"מידת הדמיון או השוני בין ההרחבות אינה יכולה להיגזר מעצם ייעודם המקורי".

וסיכם ואמר כי -

"יש לפרש את המונח 'הרחבה דומה' כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה ובמכלול הפרמטרים הנתונים... יש לבחון בין היתר את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבנין, אין מקום להכשירה".

בית המשפט גם מפנה לע"א [י-ם] 3235/02 אביב נ' גדולטר-בכבוד מיום 2.3.03 שמושתת על מדד נוסף, והוא - דמיון בין הרחבות:

"הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי".

(ג) יישום המדדים הללו על ההרחבות נושא הדיון כאן מביא אותי למסקנה שאין לראות בהרחבה שבצעו רוזנטל, שהינה סיפוח חדר ההסקה המשותף, דמיון לזה המתוכנן על ידי הנתבעים, בגדרה ניתן לייחס להם הסכמה קונסטרוקטיבית: ההרחבה של רוזנטל אינה חורגת מקווי הבנין המקוריים, אינה יוצרת שטח מבונה בחינת 'יש מאין', אינה משנה את אופיו של הבית, חזותו והסימטריה המאפיינת אותו.

(ד) הנתבעים גם העלו טענה ולפיה בעלת הדירה לא הגישה בעצמה את התביעה, אלא בעלה, שהוא נטול זכויות קנייניות בה. הגנה זו ממילא אין בה כדי לראות מצד רוזנטל משום הסכמה. כבר נאמר לעיל כי היעדר התנגדות [היינו אי הגשת תביעה משפטית] אינה מלמדת על הסכמה פוזיטיבית. זאת ועוד, שרה רוזנטל בעלת הדירה העידה על התנגדותה לתכנית הבניה. יתרה מכך, הנתבע משה בכר בעצמו ראה ברוני רוזנטל בעל דברים בבואו להחתים אותו על טופס ההסכמה לעיריה. אשתו לאה בכר בחקירה הנגדית לא כפרה בטענה זו. ואם לא די בכך אזי האסיפה הכללית של בעלי הדירות שדנה בתכניות הבניה התקיימה בביתה של משפחת רוזנטל בה השתתף גם רוני רוזנטל התובע. למעלה מהצורך ייאמר כי מקרה של בני זוג, וככל שמדובר בהצבעות שעניינן קבלת החלטות בעניין הבית המשותף, ניסיון החיים מלמד שחזקה על בעל דירה שעמדו ניתנה על דעתו של בן הזוג, אשר הסמיכו בעל פה לייצגו. מכל מקום, צד ג', במקרה זה הנתבעים, יכלו להניח, על פי מעורבותו של בן הזוג נטול הזכות הקניינית, כי הוא שלוחו של בעל הזכות הרשומה.

71. עמדת משפחת פנצ'ק –

(א) העדה פנצ'ק דינה, שהנה בעלת דירה בקומה העליונה באופן שמפלס דירתה מקביל למפלס גג הממ "ד המתוכנן, הביעה חשש מפני פריצות של גנבים לנוכח קרבת מפתחי דירתה אל הגג האמור. היא גם רואה סיכון בטיחותי בגג הממ"ד בשל גובהו מעל פני הקרקע הטבעית. במעקה הגג בגובה של 110 ס"מ שהוצע כי יהיה בנוי מחומר שקוף היא רואה "אקווריום" שישפיע על המראה הניבט ממפתחי הדירה. "זה לא הנכס שקניתי" כלשונה. העדה הבהירה בעדותה כי חדר ההסקה המשותף נחלק בין בעלי דירות לרבות הנתבעים מס' 2, ומשמש אותם כמחסנים.

(ב) אכן כטענת הנתבעים בסיכומיהם, הממ"ד לא יסתיר את הנוף הניבט ממפתחי דירת פנצ'ק אולם ישנה אותו. מגדל הממדי"ם גם ישנה את המראה הניבט מהרחוב לעבר הבית לרבות לעבר דירת פנצ'ק.

81. עמדת משפחת נוימן -

(א) יהושע נוימן שדירתו משיקה לדירת הנתבעים מס' 1 ממקד את התנגדותו בפגיעה שתוסב לחזות הבית "הבניין הוא אחד היפים ברחוב, הבנייה של התוספות הבולטות שתהיינה בצד הקדמי והצפוני של הבניין תגרומנה לשינוי מכוער ולא סימטרי של הבניין" – עדותו בעמ' 8 לפרו'.

(ב) כנגד עמדה זו טוענים הנתבעים בסי כומיהם כי העד לא ראה כלל תוכניות ולהתנגדותו אין כל בסיס.

(ג) אלא שטיעון זה הוא להם, לנתבעים, לרועץ מהטעם שדווקא מהטעם ש העד לא ראה כלל תוכניות יש להתנגדותו בסיס ולא ניתן לייחס לו הסכמה.

(ד) יתרה מכך, הפסיקה הכירה בזכות לשימור חזות ארכיטקטונית של בית משותף כזכות לגיטימית כנגד זכותו של האחר לבנות ממ "ד, ואפנה לפסה"ד בענין צבי נטלה שם נפסק כי :

"חזותו המיוחדת של הבית היא עניין שיש לו ערך, וזכאים בעלי הדירות בבנין להבטיח שמירת ערך זה".

וכן פסק הדין בענין זינגר נ' חדד הנ"ל שם נדונה הוספת חדר על גג הבית :

"בניית חדר על גג הבית המשותף, יש בה כדי לגרום לשינוי ארכיטקטוני וויזואלי של הבניין, שעה שלחזותו של בניין יש ערך וזכאים בעלי הדירות בבנין להבטיח שמירת ערך זה". [פיסקה 19 לפסה"ד].

91. עמדת משפחת פטרוזיל –

(א) הנתבעים מבקרים את עמדתו של זה : מלכתחילה חתם כמסכים על טופס הבקשה לעירייה, ולאחר מכן הפך את עורו, כנראה בלחץ בעלי דירות אחרים. מדירתו שלו לא נצפית אפילו תוספת הבניה, מה שמעמיד את ההתנגדות בחוסר סבירות.

(ב) בעדותו מיקד מנחם פטרוזיל את ההתנגדות בכיעור שיסב מגדל הממ"דים. את התנגדותו בדיעבד חרף הסכמה לבניה מלכתחילה הוא מבסס על היעדר התעמקות במיקומה של הבניה המתוכננת ובהשלכותיה על הבית המשותף.

(ג) הגם שעמדתו של תובע זה רפה- משהו, לא משכנעת, היא לא משנה את התוצאה אליה אני מגיעה בסופו של דבר.

02. עמדת משפחת לצרס -

(א) העד, עו"ד במקצועו, העיד כי אכן חתם על טופס ההצהרה לעירייה כמסכים לבניה, אולם ראה בהסכמה זו משום הסכמה עקרונית ולא ספציפית שכן לא הונחו בפניו תכניות בניה. רק כשהבין את ההשלכות של מגדל הממדי "ם המתוכנן על אוורור ואור במחסן דירתו כמו גם על חזות הבית המשותף הביע התנגדות לו.

(ב) נוסחו של טופס ההסכמה לעיר ייה [מוצג נ 3/] מחזק את העדות . מהות הבקשה מוגדרת שם כ"בקשה למתן היתר בניה לתוספת ממדי "ס במפלס 3 ו-4". אין שום איזכור לבניה מחוץ לקווי המיתאר של המבנה , כמו גם לא להיקף הבניה מבחינת גובה, שטח, פרופורציות וכד' ; תיאור הבניה המתוכננת הוא לוקה במ ידה שאינה מאפשרת התייחסות עניינית להשלכותיה על הבית המשותף.

(ג) עדות זו מחזקת את חשיבות גיבוש והצגת תשריט ספציפי המכיל את כל פרטי הבניה המתוכננת בפני בעלי הדירות עוד קודם להגשת הבקשה לעיר ייה ; התשריט חובה שיהיה חלק אינטגרלי מטופס ההסכמות לעירי ייה, ולא ייתפס כמסמך טפל מאוחר יותר או נסתר מעין . רק כך הסכמה תהווה הסכמה מח ייבת במשמעות דיני המקרקעין.

12. נציג של כל דירה מבין דירות הנתבעים העיד אף הוא לאמור :

(א) העד אברהם מזרחי נימק את הצורך בממ "ד כמרחב שמגן על החיים , היינו צורך בטיחותי . הוא הדגיש את המרחק המשמעותי (40 מדרגות) בין דירתו לבין המקלט המשותף . הוא גם שלל פגיעה כלשהי ש יסב מגדל הממ "דים לאיזה מהדיירים האחרים בבית המשותף . בחקירה הנגדית הודה העד כי קודם להגשת הבקשה להיתר בנייה , לא הוא ולא אשתו , לא פנו לדיירים בבקשה לקבל את הסכמתם לתוכנית . על פי עדותו הנתבע משה בכר הוא שעשה זאת . יחד עם זאת , התקיימה אסיפת דיירים בדירת מש ' רונטל, שם הודה העד כי "היה קרע" . חרף זאת, המשיכו הוא והנתבע האחר בהליכי הרישוי למגדל הממ "דים, בנימוק ש"החיים שלי לא יהיו בידייך , כל אחד יכול לבוא ולהצטרף ... בתשובה לשאלתך אם המשכנו לפעול למרות התנגדות הדיירים אני משיב שפעלנו לפי החוק " (עדותו בעמ' 28 לפרו'). העד נשאל אודות אפשרות של שיפור מיגון של אחד מחדרי דירתו והשיב כי להערכתו ממ"ד הוא מבנה בטוח יותר . העד שלל השפעה כלשהי של מגדל הממ "דים מבחינת אור ואוויר על מידת ההנאה של בעלי הדירות האחרים מדירותיהם או מהרכוש המשותף.

(ב) העדה לאה בכר הדגישה את העדר הנגישות שלה וש ל בני ביתה אל המקלט המשותף בשל 40 מדרגות המפרידות בין הללו, בעיקר לנוכח הצורך של בתה הלוקה ב 100% נכות. הממ"ד הוא עבור בני ביתה צורך קיומי המבטל את משקלה של כל פגיעה אסתטית לחזות הבית . העדה אישרה כי שינויים ככל שביצעה בעבר בדירתה באופן שנצפו כלפי חוץ , קדמה להם הסכמה בפועל של יתר בעלי הדירות , גם אם הנם נטולי היתר בנייה . על פי עדותה בעלי הדירות אשר חתמו כמסכימים מלכתחילה הסתמכו על סקיצה שהוצגה להם על ידי בעלה ; הסקיצה לא היתה בידי העדה ולא הוגשה כראיה . לדבריה "יכול להיות שאחר כך הארכיטקט עשה על סמך זה תכנית מפורטת. אני לא יודעת מה הוא הגיש לעירייה " – עמ' 29 לפרו'. בתשובה לשאלה האם נכון שבאסיפת הדיירים בעלה נתן הסבר על הבנייה אך לא הציג תכניות מפורטות היא השיבה "הוא הציג את מה שהיה לנו " . בתשובה לשאלה אם נכון שבאותה אסיפת דיירים כל הדיירים שהשתתפו הביעו התנגדות ל תכנית השיבה

העדה "לא הייתה ממש התנגדות, היתה מורת רוח ולא הייתה החלטה ... לא כולם אמרו אני מתנגד" – עמ' 30 לפרו'.

(ג) אודה שלבי עם צרכי משפחה זו, שהם צרכים אמיתיים מוכחים. יחד עם זאת על רקע היעדר הסכמת יתר בעלי הדירות אין מניעה כי ימגנו את אחד מחדרי דירתם לפי תקנים מקובלים.

22. סוגיית תום הלב במימוש זכויות קנייניות –

(א) "אכן נוכח השיקולים השונים אלה מול אלה בסוגיה שבפנינו הובעו גישות שונות באשר להיקף שיקול הדעת המסור לבית המשפט בבואו להגן על זכות הקניין. עם זאת גרעין ההלכה לפיה ההגנה על זכות הקניין כפופה לעקרונות של צדק הגינות ותום לב קנתה אחיזה איתנה בפסיקה ואין עליה עוררין" – ציטוט מפסקה 13 לחוות דעתה של כב' השופטת חיות בע"א 8661/10 נעמה נ' תורכיה שניתן בעצם הימים האלה [19.2.12]. והשאלה היא אכן אם יש לראות בעמדות התובעים משום חוסר תום לב, כטענת הנתבעים. אלו האחרונים בדעה כי כף הזכות לצידם, בעיקר על רקע הצרכים הביטחוניים שהודגשו על ידיהם. הנתבעים לא התעמתו כלל עם השאלה על שום מה אין בשיפור מיגון של איזה מחדרי דירותיהם כדי להוות מענה ראוי דיו לצרכים הביטחוניים בנסיבות בהן מרבית בעלי הדירות מתנגדים.

(ב) התנהגות בתום לב במימוש זכויות קנייניות מחייבת לא רק את התובעים אלא – ואפשר שבעקר – את הנתבעים כמי שחפצים לבנות. פסיקה ענפה דנה בסוגיית תום הלב במימוש זכויות קניין, ואפנה למקצתה:

בפסה"ד בענין נטלה צבי שם טען המיעוט אשר בקש להרחיב את דירתו כי התנגדות הרוב נטולת תום לב, מצא כב' השופט כהן לציין:

"סעיף 14 לחוק המקרקעין, עליו משליכה המערערת את יהבה, הוא סעיף הדדי. הוא חל על כל בעלי הרכוש המשותף באותה מידה. כשם שהמשיבים אינם זכאים לעשות שימוש בזכויותיהם הקנייניות, כשלעצמן, לשם גרימת נזק או אי נוחות למערערת, כך אף המערערת אינה רשאית לעשות שימוש בזכויותיה הקנייניות, כשלעצמן, לשם גרימת נזק או אי נוחות למשיבים. סעיף 14 לחוק המקרקעין פועל לזכותה או לחובתה של המערערת, ממש כשם שהוא פועל (בהתאמה) לחובתם או לזכותם של המשיבים".

וגם בפס"ד בענין קיסרי נ' שלומוב, בהתייחסו להערכת נימוקי ההתנגדות, אם סבירים הם אם לאו מחווה השופט סוקול, כדעת הרוב, דעתו ולפיה:

"...איני יודע מהם אותם נימוקים שיעמדו במבחן האובייקטיבי , ודומני כי התנגדותו של אדם לעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף תהא בדרך כלל התנגדות עניינית. אין כל מקום לכפות על אדם לוותר על קניינו רק בשל רצון של שכן לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף ... גם התנגדות בשל החשש לירידת ערך הדירה של המתנגד אינה חסרת תום לב ... עיקרון תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתי להסכים לבנייה בר כוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים". [ההדגשה שלי-צ.פ.]

מסכם השופט סוקול וקובע כי :

"בניית הממ"ד ושאר העבודות בלי שהתקבלה הסכמה מוקדמת וללא נקיטת כל הליך לכפות על המערערים את הבניה, היא שמהווה חוסר תום לב מצד המשיבים".

ככל שעוד נחוץ, אפנה לע"א 17181-05-11 גורי אברהם נ' פדאל יאיר [מיום 20.9.11] שדן בהיקף סמכותה של הערכאה השיפוטית לבחון את נימוקי המתנגדים לבניה שם צוין :

"...גם על פי הדעה של הסמכות לבחון את נימוקי ה מתנגדים, סבור ההרכב שטענה כבוד המפקחת שסברה במסגרת סמכותה לבחון את הנימוקים כי יש לראות את אלה כטעמים שהועלו שלא בתום לב וכי סמכותה של הרשות השופטת לבוא ולשקול את השיקולים על ידה , במקום הדיירים האחרים . סמכות כזו אינה קיימת".

32. סוגיית השיהוי –

(א) הנתבעים מצביעים על השיהוי בו לוקה התביעה שכן הם חרגו בכ- 30 יום מפרק הזמן שנקצב ל הם ע"י ועדת הערר להגיש תביעה . התובעים לעומת זאת לא מוצאים מתום בעיתוי הגשת התביעה מנימוקים כמפורט בסיכום מטעמם שעיקרם היעדר זכותם של הנתבעים להיבנות מרמיסת זכות קניינית של משניהם בעילה של הסתמכות [שהיא ה'לבוש' האזרחי ל'שיהוי'] .

(ב) לדעתי לוח הזמנים להגשת תביעה ות נקצב בדין ולא בהחלטת ועדת הערר ; החלטתה היא אך זאת : התליית למשך 30 יום.

(ג) יתרה מכך, לכאורה סעיף 71ג' לחוק המקרקעין הוא שקוצב את לוח הזמנים הגשת תביעה, ובתנאיו חובה לעמוד. הסעיף קובע לאמור :

"(א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב[א] וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו...רשאי לפנות למפקח בתביעה.

(ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה..." וגו'.

(ד) במקרה דנן **כלל לא** התקבלה החלטה כאמור בסעיף 71ב[א], כלומר לא התקבלה החלטה של 60% מבעלי הדירות להוציא חלקים מהרכוש המשותף לצורך בנית ממ"ד, הווי אומר שהתביעה אינה באה בד' אמות הזמן שנקצב בסעיף חוק זה. התביעה מושתתת על עילת פגיעה ברכוש המשותף והסגת גבולו [התקנון המצוי], עילות שלוח הזמנים להגשתן לא התיישן, לא כל שכן על רקע ידיעה מפורשת של הנתבעים אודות התנגדות נחרצת של התובעים.

42. בשל הטעמים המפורטים לעיל, בהצטרבם, נראה לי כי נכון לקבל את התביעה ולאסור לעת הזו על הנתבעים את מימוש היתר הבניה שבידיהם לבניית מגדל הממדי"ם, כל עוד הבניה המתוכננת של הנתבעים אינה נתמכת ברוב פוזיטיבי ומפורש של 60% מבעלי הדירות.

52. בנסיבות, ולו כדי למתן את היחסים המתוחים בין בעלי הדיר וות שהם לחלוטין תוצאתה של המחלוקת שנסבה סביב בניית הממדי "ס, מצאתי להעמיד את ההוצאות שתושנתנה על כל אחת ממשפחות הנתבעים לכל התובעים יחד, כולל שכ"ט ומע"מ על סך של 4,000 ₪, סכום שלחלוטין אינו משקף את ההוצאות הראויות. הסכום ישולם לידי ב "כ התובעים, ועניין הוא לת ובעים להחליט כיצד יחולק הסכום ביניהם.

62. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה [16.12.10] ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כט' בשבט תשע"ב (22.2.2012).

העתיקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין